

1500653-73.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... condenação dos réus, pelo crime de tráfico de drogas, e suas absolvições pelo delito de associação (fls. 420/430).

Por sua vez, a defesa de Lucas pugnou por sua absolvição por carência probatória (fls. 434/445). A defesa de Marcos trilhou o mesmo caminho. Alternativamente, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como das atenuantes ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500653-73.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500653-73.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2184334/2021 - 1º Distrito Policial de Lorena, 18933027 - 1º Distrito Policial de Lorena, 594/21/204 - 1º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS DA SILVA GARCIA e outro

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de LUCAS DA SILVA GARCIA e MARCOS PAULO DA SILVA VIEIRA, qualificados nos autos, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06; conforme inicial acusatória (fls. 179/181).

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados, apresentando defesas preliminares (fls. 202/206, Lucas, e 198, Marcos). A denúncia foi recebida em 07/10/2021 (fls. 233/237).

Durante a instrução criminal foram ouvidas as testemunhas. Ao final, os acusados foram interrogados. Encerrada a instrução, as partes apresentam suas alegações

finais por meio de memórias.

O Parquet pugnou pela parcial procedência da ação penal, com a consequente condenação dos réus, pelo crime de tráfico de drogas, e suas absolvições pelo delito de associação (fls. 420/430).

Por sua vez, a defesa de Lucas pugnou por sua absolvição por carência probatória (fls. 434/445). A defesa de Marcos trilhou o mesmo caminho. Alternativamente, em caso de condenação, pleiteou o reconhecimento do tráfico privilegiado, bem como das atenuantes da confissão e da menoridade relativa (fls. 459/469).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade narcotraficante está comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão (fls. 21/23), laudo de constatação provisória (fls. 103/105) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 307/309), com resultados positivos para "cocaína", substância presente na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores; posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa.

O mesmo se pode dizer quanto à prova de autoria, com exceção do delito de associação para o tráfico de drogas. Senão vejamos.

Ouvido em juízo, o policial militar André Luiz de Jesus da Silva disse que durante patrulhamento de rotina recebeu denúncia indicando que um indivíduo conhecido por "Lucas" estaria transportando entorpecentes em seu veículo, vindo de Cachoeira Paulista/SP para esta urbe. Passado algum tempo, localizou Lucas conduzindo um veículo e, devido aos informes anteriores, decidiu abordá-lo. Durante a revista, nada de ilícito foi achado em seu posse. Porém, em busca no veículo, o depoente encontrou apetrechos comumente utilizados no tráfico, além de entorpecentes. Nesse momento, o acusado confessou a guarda de dinheiro proveniente do vil comércio em sua residência, além de mais narcóticos, estes guardados na residência do corréu Marcos. Ato contínuo, dirigiu-se a tal imóvel, ocasião em que Marcos admitiu a posse de droga, indicando o esconderijo (sob o seu guarda-roupas). Questionado, disse que Lucas estava sozinho no veículo no momento da abordagem, apenas encontrando sua esposa, o corréu Marcos e um "motoboy" ao chegarem no restaurante daquele. A testemunha afirmou que nunca ouviu falar das pessoas citadas por Lucas em sede policial, e que não se recorda de ter apreendido objetos de outras pessoas no interior do veículo, apenas o aparelho celular que Lucas declarou pertencer a sua mulher.

Seu colega de farda Danilo Rodrigues de Sousa fez coro às suas palavras. Disse que, de fato, já havia notícias informais indicando o envolvimento de Lucas no vil comércio, inclusive, com a utilização do veículo apreendido, e que na data dos fatos recebeu a informação no sentido de que este voltava de Cachoeira Paulista/SP, trazendo drogas de lá. Com relação a Marcos, contou que não o conhecia até o dia da ocorrência.

A testemunha Marcelo Aparecido de Jesus contou que reside próximo ao local dos fatos e, na data em questão, presenciou os policiais militares abordando três pessoas em um veículo. Contou que o pai de Lucas o procurou para que testemunhasse, e que outras pessoas, residentes em uma fazenda próxima igualmente viram o ocorrido. A testemunha asseverou que passou pelo local dos fatos por volta das 18h30, e que nesse horário somente havia uma viatura policial abordando o veículo, e as três pessoas. Ao final, disse não se recordar do modelo/marca da viatura.

O escrivão de polícia Cleber Pereira Araújo declarou que acompanhou uma mulher, que retirou os objetos do carro apreendido na posse de Lucas, não se recordando, no entanto, quais eram, descartando que fosse algum objeto ilícito.

Em sentido semelhante depôs a autoridade policial responsável pela lavratura do auto de prisão em flagrante (Daniel Souza Baptista Castro).

A testemunha José Rafael Guatura Barbosa, vizinho de Lucas, contou que estava na companhia do acusado quando este foi preso. Disse que no dia dos fatos estava em Canas, onde o seu carro estragou. Como Lucas era seu vizinho, ligou para que ele fosse socorrê-lo. Quando voltavam foram abordados pela polícia, acabando por deixar a chave do seu carro dentro do veículo de Lucas. O depoente, residente nesta urbe, declarou que estava em Canas/SP por conta de um festival de pipas que ocorria nesta cidade, juntamente com seu amigo Carlos Henrique (testemunha Carlos Henrique Valim de Carvalho da Costa). Disse que os policiais pesquisaram sobre o passado criminal do trio e, ao notarem que Lucas possuía registro desabonador pretérito o levaram para a casa dele, permanecendo junto à Carlos Henrique no local da abordagem por mais meia hora, até serem liberados. Como havia deixado a chave de seu automóvel no interior do veículo de Lucas, dirigiu-se à delegacia para busca-la, ocasião em que encontrou a esposa de Lucas naquele local. Disse que durante a diligência fiscalizatória nada de ilícito foi encontrado seja em sua posse, ou mesmo no carro, e que havia mais de cinco policiais no local. Afirmou que um policial levou o carro de Lucas, enquanto outros dois ou três o levaram do lugar da abordagem. A testemunha contou que foi embora a pé do local, juntamente com Carlos Henrique, e, após chegar em sua casa o convidou Carlos a ir até a delegacia com este pegar os pertences dos dois que haviam ficado no veículo arrestado (chave do seu carro, e carteira com documentos de Carlos Henrique). Aduziu que na delegacia, após falar com o advogado, a esposa de Lucas conseguiu a liberação dos pertences. Indagado, disse que no distrito policial nada falou que acompanhou a abordagem de Lucas, que foi o advogado dele quem assim afirmou isso.

A testemunha Carlos Henrique Valim de Carvalho da Costa trilhou o mesmo caminho em seu depoimento.

Em seu interrogatório, Lucas alegou inocência. Afirmou que trabalhava em seu restaurante de comida japonesa, quando José, seu vizinho, ligou clamando por ajuda, dizendo que seu carro havia quebrado. Disse que os três foram abordados quando retornavam de Canas/SP, sendo apenas liberados seus amigos. Aduziu que os policiais militares invadiram sua residência, assim como a casa do corréu Marcos e, mesmo sem apreenderem nada de ilícito, ambos foram levados à delegacia. Lucas contou que os amigos que o acompanhavam foram ao distrito buscarem os pertences que lhes pertenciam, e que ficaram dentro do seu veículo. Questionado, disse o interrogando que já conhecia os policiais militares que o prenderam, e que era constantemente abordado pelos mesmos, citando os nomes dos policiais Jesus e Nilton, e que conhecia o corréu Marcos apenas do trabalho. Afirmou que não foram localizados entorpecentes em seu carro, ou em sua casa, mas apenas dinheiro nesta última, que guardando para comprar peixes para seu restaurante. Por fim, disse que em momento nenhum confessou ou afirmou que ele e/ou Marcos possuíam entorpecentes.

Lado outro, Marcos confessou parcialmente a acusação que lhe pesa em sua autodefesa. Contou que a única relação que mantinha com Lucas era profissional, por trabalhar em seu restaurante de comida japonesa, confessando que, de fato, guardava parte dos entorpecentes apreendidos em sua residência para outra pessoa, pelo valor de R\$ 200,00 (duzentos reais). Admitiu que revelou aos agentes públicos a posse dos narcóticos, e que os guardava havia um dia, para pessoa de vulgo "Léo". Esclareceu que autorizou a entrada dos policiais militares em sua residência, e que não conhecia os agentes estatais que realizaram sua prisão.

Eis, portanto, o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a confissão parcial do corréu Marcos está em linha com as demais provas do processo.

Sabe-se que a confissão judicial isenta de vícios e coações, como a trazida pelo increpado, fornece elemento seguríssimo de prova, notadamente quando amparada por outros elementos de convicção, tal como no presente caso.

A propósito, em recente julgado:

"Apelação da Defesa - Tráfico de Drogas - (...) Consistentes relatos dos policiais militares responsáveis pela abordagem ao réu - Confissão judicial do réu - Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros - Condenação mantida - (...) - Recurso de apelação parcialmente provido, sem reflexo na pena final". (TJSP; Apelação Criminal 1503582-66.2021.8.26.0302; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jaú - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/06/2022; Data de Registro: 30/06/2022) (Ênfase na reprodução).

Registre-se que a admissão de culpa de Marcos foi até mesmo corroborada pelo próprio Lucas que, embora não tenha confirmado a apreensão dos entorpecentes, admitiu que os agentes da lei estiveram na residência daquele.

Assim, em relação ao corréu Marcos, o caso é de condenação pelo delito de tráfico de drogas.

O mesmo destino condenatório terá Lucas, conforme passo a expor.

Inicialmente, insta salientar a ampla credibilidade que detém as palavras de policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de segurança pública.

Neste sentido, confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça deste estado:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim é, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas também por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressaltadas pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, como no caso das testemunhas destes autos; poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisor o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão

Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Pois bem. Depreende-se dos depoimentos dos policiais militares que, após receberem informações anônimas indicando que Lucas transportava entorpecentes, este foi por eles surpreendido conduzindo, sozinho, veículo em cujo porta-malas foram encontradas drogas.

Não olvido que duas testemunhas, ligadas ao réu (José, seu vizinho, e seu amigo Carlos Henrique), afirmaram o contrário em pretório, no caso, que ambas estavam no veículo com Lucas no momento da abordagem policial, e que nenhum entorpecente foi apreendido em suas posses.

Porém, não bastasse a proximidade existente entre elas e Lucas - afinal, não se pede a um vizinho distante para ser buscado em outra cidade, por conta de uma pane automotiva -, nota-se a existência de contradição entre as falas das testemunhas arroladas pela defesa.

Decerto, enquanto José e Carlos Henrique disseram que no momento da abordagem haviam várias viaturas policiais, a testemunha Marcelo afirmou ter visualizado três indivíduos sendo abordados por uma única viatura policial.

Frise-se, outrossim, que o escrivão de polícia e a autoridade policial não respaldaram a narrativa defensiva de que José e Carlos se encontravam no veículo de Lucas, apenas confirmaram a retirada de objetos pessoais, sem interesse policial, do veículo apreendido.

Assim, encampar a narrativa defensiva significaria não só fechar os olhos a uma realidade manifesta nos autos e dar costas ao óbvio, em total e completo desapego as normas da verdade e do bom senso, como também desprestigiar as palavras dos próprios policiais, agentes que gozam de ampla credibilidade junto ao Poder Judiciário, sobretudo, por não terem qualquer interesse na incriminação de inocentes.

Significa dizer, Lucas não demonstrou estratégia criada para incriminá-lo, nem apontou motivo sério que permitisse tal conclusão, citando nome de policial militar que sequer participou da ocorrência em questão (Nilton), logo, não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) - OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS - PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS - NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE - O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS - A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO - RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Afinal, como fundamentado acima, a ideia de que possam os agentes da lei "forjarem" acusações em desfavor de pessoas sem motivo algum, às escâncaras, é um verdadeiro absurdo! Ademais, por qual razão os policiais incriminariam Lucas injustamente, e agiriam dentro da lei com Marcos, que admitiu a guarda de drogas?

Por fim, convém esclarecer não ser necessário para configuração do delito de tráfico que o agente seja flagrado em atos de mercancia, visto que a prática de qualquer uma das múltiplas ações previstas no tipo penal já é suficiente para tal fim, sendo certo que a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como nos presentes autos, diante da quantidade de entorpecentes e apetrechos comumente utilizados para a venda de entorpecentes no varejo (balança de precisão e microtubos, do tipo eppendorf).

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de drogas – Recurso defensivo – Autoria e materialidade delitivas comprovadas – Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares – Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 – Descabimento – Tipo penal que prevê diversas condutas – Desnecessidade da prova da efetiva mercancia – Condenação mantida – (...) Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Assim, impõe-se a condenação de Lucas pelo crime de tráfico de drogas.

De outra banda, quanto ao crime de associação para o crime de tráfico de drogas, de rigor a absolvição da dupla.

Com efeito, além da pluralidade de agentes, o delito do artigo 35, da Lei de Tóxicos pressupõe a comprovação do animus associativo, a estabilidade, permanência e organização do grupo, com funções pré-determinadas entre seus membros, bem como relação de hierarquia entre eles, o que não se verificou na hipótese.

Confira-se, mesmo entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico e associação. (...) Associação – provas insuficientes. O crime em tela exige a vontade de dois ou mais agentes se associarem (animus associativo) e sua consumação se dá com a reunião estável e permanente, dispensando a prática do crime-fim. Não se demonstrou, contudo, mínima organização e hierarquia entre eles o que, após cotejar todos os elementos analíticos inseridos nos autos, não emerge com clareza meridiana o vínculo associativo. (...) Recurso parcialmente provido, nos termos do v. Acórdão”. (TJSP; Apelação Criminal 0002107-90.2016.8.26.0443; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piedade - 1ª Vara; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017) (ênfase minha).

Delimitada a responsabilidade penal dos acusados, passo à dosimetria de suas penas.

a) LUCAS DA SILVA GARCIA:

A única condenação do réu configura a reincidência, motivo pelo qual será considerada na etapa subsequente.

Todavia, à luz da vultuosa quantidade de entorpecentes (816,92 gramas de “cocaina”), há que se reconhecer a maior reprovabilidade da conduta em questão.

Assim, estabeleço a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, ou seja, em 06 anos e 08 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na etapa intermediária, como tangenciado acima, o réu é reincidente (autos nº 0001443-31.2016.8.26.0323 - fls. 266/268). Logo, agravo a pena em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777

(setecentos e setenta e sete) dias-multa, ausentes outras circunstâncias modificadoras.

Incabível o reconhecimento da figura privilegiada do tipo, por conta do seu passado criminal comprometedor.

Outro não é o entendimento do E. TJSP:

“Apelação – (...) Tráfico de entorpecentes – Agente reincidente – Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos. (...) Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa – Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1500082-57.2018.8.26.0573; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020) (ênfase na reprodução).

b) MARCOS PAULO DA SILVA VIEIRA:

O réu é primário e de bons antecedentes (fls. 269 e 383/384).

Porém, assim como mencionado na dosimetria do coacusado acima, a quantidade de entorpecente apreendida sob a sua guarda (383,91 gramas, de “cocaína”), igualmente excede a culpabilidade normal à espécie, à vista do bem jurídico tutelado pelo tipo penal em questão.

Portanto, a fim de manter a proporcionalidade, fixo sua basilar com elevação de 1/4 (um quarto) do mínimo previsto na lei. Assim, parte-se de uma pena de 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço em seu favor as atenuantes da menoridade relativa (fls. 03), e da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), reconduzindo-a novamente ao piso legal, conforme jurisprudência sedimentada, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, tornada definitiva, à míngua de outras causas.

Inviável conceder-lhe a redutora prevista no parágrafo quatro do artigo 33 da Lei de Tóxicos, posto que as circunstâncias do caso concreto revelam sua profunda intimidade com o narcotráfico, a despeito da sua condição de primário aos olhos da lei penal.

Afinal, traficante algum confiaria à um neófito a abissal quantidade de droga encontrada sob sua guarda, sem olvidar do encontro de mais drogas e de apetrechos (balança de precisão, pinos plásticos, do tipo eppendorf), com Lucas, tudo a reforçar a conclusão acima exarada.

Neste sentido, trago à colação, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. (...). 1. Na hipótese dos autos, a causa especial de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 foi afastada não somente pela quantidade de drogas apreendidas - 17kg de maconha -, mas, também, em virtude da existência de outros elementos fáticos, notadamente a apreensão de balança de precisão e outros apetrechos para a prática da traficância. (...) 2. A quantidade e a natureza da droga demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento do aspecto qualitativo (regime) da pena. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 707.818/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA

TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022) (Sublinhei).

Aliás, como não existe prova direta dessa circunstância, dedicar-se à atividade criminosa, como bem lançado pelo Ministro Luiz Fux, do C. Supremo Tribunal Federal, "os criminosos não circulam com uma 'carteira de identificação de pessoa dedicada a atividades criminosas'", é exatamente essas circunstâncias que comprovam a sua dedicação, conforme julgado que assim se encontra a ementa:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRESUNÇÃO HOMINIS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS. APTIDÃO PARA LASTREAR DECRETO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06, ANTE A DEDICAÇÃO DO AGENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. O princípio processual penal do favor rei não ilide a possibilidade de utilização de presunções hominis ou facti, pelo juiz, para decidir sobre a procedência do ius puniendi, máxime porque o Código de Processo Penal prevê expressamente a prova indiciária, definindo-a no art. 239 como "a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias". Doutrina (LEONE, Giovanni. Trattato di Diritto Processuale Penale. v. II. Napoli: Casa Editrice Dott. Eugenio Jovene, 1961. p. 161-162). Precedente (HC 96062, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 06/10/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-02 PP-00336). 2. O julgador pode, através de um fato devidamente provado que não constitui elemento do tipo penal, mediante raciocínio engendrado com supedâneo nas suas experiências empíricas, concluir pela ocorrência de circunstância relevante para a qualificação penal da conduta. 3. A criminalidade dedicada ao tráfico de drogas organiza-se em sistema altamente complexo, motivo pelo qual a exigência de prova direta da dedicação a esse tipo de atividade, além de violar o sistema do livre convencimento motivado previsto no art. 155 do CPP e no art. 93, IX, da Carta Magna, praticamente impossibilita a efetividade da repressão a essa espécie delitiva. 4. (...) 5. In casu: (i) consta dos autos que o paciente, em concurso com um adolescente, transportava e tinha em depósito, para consumo de terceiros, 6,280 Kg (seis quilos e duzentos e oitenta gramas) de maconha, e 787,9 gramas de cocaína em pedra, acondicionadas em invólucros, disso resultando sua condenação a 5 (cinco) anos de reclusão e a 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial fechado, por estar incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006; (ii) para fundamentar a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Juízo de origem ponderou negativamente as circunstâncias do crime, destacando a forma como a droga estava acondicionada e o concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, de forma a facilitar a comercialização, tudo conduzindo à conclusão de que não se trata de uma ação individual e ocasional, mas sim que o paciente se dedicava a atividades criminosas; (iii) apesar da robusta fundamentação, sustenta o impetrante que não houve adequada motivação do arredamento da aludida minorante, pois entende que teria sido considerada apenas a quantidade da droga. 6. O juízo de origem procedeu a atividade intelectual irrepreensível, porquanto a apreensão de grande quantidade de droga é fato que permite concluir, mediante raciocínio dedutivo, pela dedicação do agente a atividades delitivas, sendo certo que, além disso, outras circunstâncias motivaram o afastamento da minorante. 7. Ordem denegada". (STF; HC 101.519/SP; Relator: Min. Luiz Fux; Órgão Julgador: 1ª Turma; Data do julgamento: 20/03/2012; Data da publicação: 26/04/2012).

Assim, como determina a lei, tal redutora não se destina àquele que faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, hipótese destes autos, mas sim, ao agente que age por um impulso esporádico, em caso isolado, incidindo, portanto, em situações específicas e excepcionais, quando evidenciado que o pequeno tráfico se tratou de singelo desvio na vida do acusado, não sendo o caso deste acusado.

Registre-se que tal entendimento encontra-se em linha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já que a quantidade da droga apreendida não foi o

único elemento a ensejar o afastamento do redutor, conforme fundamentação supra, não se podendo cogitar no odioso e proibido bis in idem.

A propósito, em recente julgado:

“PENAL, PROCESSO PENAL E CONSTITUCIONAL. DOSIMETRIA DE PENA. PECULIARIDADES DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE A SER OBSERVADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO PARA AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO OU MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM. NÃO TOLERÂNCIA NA ORDEM CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO PARA RESTAURAÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. Em regra, abre-se espaço, em sua primeira fase, à atuação da discricionariedade ampla do julgador para identificação dos mais variados aspectos que cercam a prática delituosa; os elementos negativos devem ser identificados e calibrados, provocando a elevação da pena mínima dentro do intervalo legal, com motivação a ser necessariamente guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Na estrutura delineada pelo legislador, somente são utilizados para a fixação da pena-base elementos pertencentes a seus vetores genéricos que não tenham sido previstos, de maneira específica, para utilização nas etapas posteriores. Trata-se da aplicação do princípio da especialidade, que impede a ocorrência de bis in idem, intolerável na ordem constitucional brasileira. 4. O tratamento legal conferido ao tráfico de drogas traz, no entanto, peculiaridades a serem observadas nas condenações respectivas; a natureza desse crime de perigo abstrato, que tutela o bem jurídico saúde pública, fez com que o legislador elegeisse dois elementos específicos necessariamente presentes no quadro jurídico-probatório que cerca aquela prática delituosa, a saber, a natureza e a quantidade das drogas para utilização obrigatória na primeira fase da dosimetria. 5. Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao status de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual. 6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7. A utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis in idem, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712). 8. A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença”. (REsp 1887511/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021) (Sublinhado meu).

O regime inicial de cumprimento será o fechado para os dois, em vista das circunstâncias concretas acima expostas, reforçada pela quantidade de entorpecente, bem como pela reincidência de Lucas, com base no artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal.

Inviável a aplicação de medidas despenalizadoras ao caso, diante do montante de

pena privativa de liberdade aplicada. De todo modo, tais medidas mostrar-se-iam insuficientes e ineficazes à reprovação da conduta, dada a hediondez do crime de tráfico e a reincidência de Lucas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, ou seja, em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira dos réus, forte nos artigos 49, § 2º, do Código Penal, e 43, da Lei 11.343/06.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

- a) condenar LUCAS DA SILVA GARCIA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, diária mínima;
- b) condenar MARCOS PAULO DA SILVA VIEIRA, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 500 (quinhentos) dias-multa, diária-mínima; e
- c) absolvê-los da imputação restante que lhes foi irrogada na denúncia (artigo 35, da Lei 11.343/06), na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nego o apelo em liberdade aos acusados. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam suas prisões preventivas se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente.

Ademais, as penas relativamente altas que lhes foram impostas, assim como o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena, conferem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Assim, visando assegurar a aplicação da lei penal, recomendem-se os acusados na prisão em que se encontram.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas - Preliminar - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Havendo recurso, no entanto, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelos vencidos.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder a sua destruição.

Decreto o perdimento da quantia (R\$ 1.770,00) e do veículo (placas LQQ6980, ano/modelo 2012/2013, marca I/VW Jetta 2.0) apreendidos em favor da União, forte no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigo 63, inciso I, da Lei 11.343/06.

Importante mencionar sobre o assunto, que o Supremo Tribunal Federal - STF decidiu em recurso extraordinário, com repercussão geral, o Tema 647, que o perdimento do bem, como no caso destes autos, do veículo, não é necessária a habitualidade na

atividade ilícita, ou que o carro tenha sido de alguma forma modificado para o transporte dos narcóticos, logo, como restou cabalmente comprovado que o réu se utilizou desse automóvel para transportar a droga, frise-se: ainda que, somente nesta ocasião, o que não é hipótese destes autos, de acordo com a palavra dos agentes da lei; é o caso do seu perdimento.

Veja-se o posicionamento daquele Supremo Tribunal, bem como do E. Tribunal de Justiça deste estado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 647 DO PLENÁRIO VIRTUAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO APREENDIDO COM O SUJEITO ATIVO DO CRIME. DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO BEM. CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGÊNCIA DE HABITUALIDADE DO USO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA OU ADULTERAÇÃO PARA DIFICULTAR A DESCOBERTA DO LOCAL DE ACONDICIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 8. A habitualidade do uso do bem na prática criminosa ou sua adulteração para dificultar a descoberta do local de acondicionamento, in casu, da droga, não é pressuposto para o confisco de bens, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 9. Tese: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento.” (STF; RE 638491; Órgão julgador: Tribunal Pleno; Relator(a): Min. Luiz Fux; Julgamento: 17/05/2017; Publicação: 23/08/2017); e

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Apelos defensivos – Inconformismo que se limita ao capítulo da sentença que decretou o perdimento do automóvel e dos telefones celulares apreendidos – Pretensão de cassação desse decreto sob os argumentos de que ele não se aplica ao tráfico privilegiado, os bens têm origem lícita e não há habitualidade no uso deles para a prática de tráfico de drogas – Caso em que esse uso está bem demonstrado – Exigência de habitualidade que é questão controversa no STJ, de modo que não há razão para abandono do entendimento adotado pela Câmara em sede de embargos infringentes: “O fato do carro, eventualmente, possuir origem lícita ou estar registrado em nome de terceiro estranho ao delito, por si só, não obsta a decretação de seu perdimento – Precedentes do STF” – (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1506190-65.2021.8.26.0228; Relator (a): Cesar Mecchi Morales; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021) (Sublinhados meus).

Assim, após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário para dar efetividade aos perdimentos. Por ora, translate-se cópia desta sentença para os autos do incidente nº 0001026-68.2022.8.26.0323.

Com relação ao celular igualmente apreendido, como nada fora produzido nos autos indicando o emprego dele no crime destes autos, ou mesmo de que era produto do mesmo e de qualquer outro delito, intime-se a quem de direito, que deverá apresentar prova idônea de sua propriedade, para retirá-lo. Não sendo tal aparelho reclamado no prazo e nos termos do § 6º, do artigo 63, da Lei 11.343/06, deverá ser revertido ao Funad; salvo se não apresentar mais conteúdo econômico. Nesse caso, após a devida certificação nos autos, fica autorizada a destruição, observadas as disposições normativas pertinentes.

Encaminhem-se ao Ministério Público, arquivos contendo a prova oral produzida, a fim de que sejam analisadas as condutas das testemunhas Carlos Henrique Valim de Carvalho e José Rafael Guatura Barbosa, na forma do artigo 40 do CPP.

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se os complementos das guias de execução; b) Intimem-se os acusados para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, conforme disposto no artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c artigo 15, inciso III, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.343/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA